

0005766-56.2016.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... 1/4, por se tratar de reincidência específica.

"PENAL. HEABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINDÊNCIA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. ACRÉSCIMO EM 1/4. RAZOABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. 0 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005766-56.2016.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 09/08/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, \_\_\_\_\_, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005766-56.2016.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMAR NEVES DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

EDMAR NEVES DIAS, Rafael Dos Santos França Rodrigues, Priscila Pereira Castanho Facchinelli e Fabrício Ferreira Da Silva, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incursos nas sanções do artigo 288, caput, do Código Penal, sendo os acusados Fabrício e Edmar também nas do artigo 297, caput, do Código Penal, bem como, este último, nas do artigo 171, caput, por 04 vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos narrados na introitoal de fls. 03/10, a saber:

"Consta do incluso inquérito policial que, em período que iniciou em data próxima e anterior ao mês de novembro de 2010 e encerrou no dia 12 de julho de 2011, nesta cidade e comarca de Itanhaém, Edmar Neves Dias, Fabrício Ferreira da Silva, Rafael

dos Santos Franca e Priscila Pereira Castanho Facchinelli, qualificados às fls. 15, 76/77, associaram-se para o fim específico de praticar crimes de estelionato. Consta, ainda, que, em data incerta, mas anterior ao dia 12 de julho de 2011, na Estrada Gentil Perez, nº 1800, bloco 11, apartamento 1134, Jardim Umuarama, nesta cidade e comarca de Itanhaém, Edmar Neves Dias, qualificado à fl. 15, alterou, em parte, documento público verdadeiro (fl. 64). Consta, outrossim, que em data incerta, mas anterior ao dia 12 de julho de 2011, na Estrada Gentil Perez, nº 1800, bloco 11, apartamento 1134, Jardim Umuarama, nesta cidade e comarca de Itanhaém, Fabrício Ferreira da Silva, qualificado às fls. 76/77, falsificou documento público (fl. 64). Consta também que Edmar Neves Dias, qualificado à fl. 15, entre os meses de novembro e dezembro de 2010, em concurso e unidade de desígnios com ouros indivíduos ainda não identificados, na cidade de São Paulo, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita consistente em R\$ 600,00 (seiscentos reais), em prejuízo da loja Leroy Merlin, induzindo pessoa ainda não identificada em erro, mediante meio fraudulento (fls. 616 e 392). Consta ainda que Edmar Neves Dias, qualificado à fl. 15, em dia incerto do ano de 2011, mas anterior a 12 de julho, em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, nesta cidade e comarca de Itanhaém, obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita consistente em R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em prejuízo do banco Itaú, induzindo pessoa ainda não identificada em erro, mediante meio fraudulento (fls. 608 e 254). Consta ainda que Edmar Neves Dias, qualificado à fl. 15, no mês de janeiro do ano de 2011, em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, nesta cidade e comarca de Itanhaém, obteve para si e para outrem, vantagem ilícita consistente em R\$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima Fátima Aparecida Capistrano de França, induzindo pessoa ainda não identificada em erro, mediante meio fraudulento (fls. 639 e 459). Consta ainda que Edmar Neves Dias, qualificado à fl. 15, em dia incerto do ano de 2011, em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, nesta cidade e comarca de Itanhaém, obteve, para si e para outrem, vantagem patrimonial ilícita consistente em R\$ 3.000,00 (três mil reais), em prejuízo do banco Itaú, induzindo pessoa ainda não identificada em erro, mediante meio fraudulento (fls. 721 e 210). Segundo apurado, os denunciados Edmar Neves Dias, Fabrício Ferreira da Silva, Rafael dos Santos França Rodrigues, Priscila Pereira Castanho Facchinelli, juntamente com outros indivíduos ainda não precisamente identificados, uniram-se para o fim de praticar crimes de estelionato, durante espaço de tempo que se iniciou antes de novembro de 2010 (estelionato praticado utilizando-se do cartão clonado de Paulo Gustavo de Carvalho) e encerrou em 12 de julho de 2011. Os denunciados possuíam, cada um, atribuições bem definidas. Fabrício e Edmar eram os responsáveis pela clonagem de cartões bancários, tarefa da qual Rafael também participava. Priscila, por sua vez, quem fazia as compras nos estabelecimentos comerciais quando da utilização de cartões bancários clonados, relativos às vítimas do sexo feminino, função que também era atribuição de Edmar e de outros indivíduos ainda não precisamente identificados quando a fraude consistia na utilização de cartões clonados de vítimas do sexo masculino. A associação criminosa foi descoberta após investigação que partiu de notícias anônimas, quando policiais civis realizaram campanha durante aproximadamente 15 (quinze) dias, quando constataram que Edmar, Rafael e Fabrício encontravam-se diariamente no condomínio situado na Estrada Gentil Perez, nº 1800, bloco 11, especificamente no apartamento nº 1134, nesta comarca de Itanhaém, local no qual se reuniram para efetuar as clonagens dos cartões e planejar os próximos crimes, que consistiam especificamente em, utilizando-se dos cartões clonados de diversas vítimas, dirigirem-se a estabelecimentos comerciais variados e, fingindo-se passar pelas pessoas cujo nome constava nos cartões, efetuarem compras, obtendo, assim, a vantagem econômica. A associação tinha como fonte de renda, ainda, a comercialização de cartões clonados a pessoas diversas, sendo cada um deles vendido por cerca de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ocorre que, após a diligente investigação, no dia 12 de julho de 2011, depois de observarem a conduta dos denunciados, policiais civis abordaram Edmar quando saía da casa acima mencionada, localizada no interior de um condomínio residencial, ocasião em que ele trazia consigo uma sacola nas mãos, seguindo-se,

então, a apreensão, no interior do veículo por ele conduzido (Chevrolet Prisma, placas EIS5709 - Peruíbe/SP), de 62 (sessenta e dois) cartões magnéticos em branco, alguns cartões com o logotipo de bancos e lojas impressos (ainda sem a anotação de nomes) e, também, de muitos cartões clonados, em nome de terceiras pessoas, acompanhados, algumas vezes, da impressão das respectivas faturas, o que facilitava a aplicação das fraudes, visto que, juntamente ao cartão já constava o endereço da vítima e o limite de compras, o que os denunciados facilmente conseguiam, pois possuíam todos os dados qualificativos dos verdadeiros correntistas/consumidores. Apurou-se, também que o denunciado Edmar falsificou a cédula de identidade acostada à fl. 65, em nome de Ivan Ferreira Claudino, nela inserindo suas digitais, bem como sua própria fotografia (laudo fl. 63, originais a fl. 65). Fabrício, por sua vez, utilizando-se de espelho materialmente falso, cuja imitação era muito próxima da legítima, inseriu o nome e a qualificação de Renato Brito Santana, apondo sua própria assinatura e sua digital (laudo fl. 63, original à fl. 65). Apurou-se ainda que Edmar, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, entre os meses de novembro e dezembro de 2010, após clonar o cartão magnético de Paulo Gustavo de Carvalho, relativo à loja Leroy Merlin, dirigiu-se àquele estabelecimento, situado na cidade de São Paulo e efetuou compra no valor de R\$ 600,00, fingindo ser o real proprietário do cartão, sendo que, após ser informado que o titular do cartão não teria sido o responsável pelos gastos, a pessoa jurídica fornecedora assumiu o prejuízo financeiro acima descrito (fls. 616 e 392). E, que Edmar, em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, utilizou-se de cartão clonado pertencente à Claudia dos Santos França, e, fingindo-se passar por ela, realizou compra em estabelecimento comercial ainda não identificado, no valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Contudo, após informar ao banco que não havia efetuado tal compra, a cobrança à titular do cartão foi cancelada, tendo o banco Itaú assumido o prejuízo financeiro (fls. 608 e 254). E, mais uma vez, que, em janeiro de 2011, agindo da mesma maneira por outra vez, Edmar, acompanhado de outros indivíduos ainda não identificados, após clonar o cartão bancário de Fátima Aparecida Capistrano de França, fingindo-se passar por ela, efetuou diversas compras, totalizando o prejuízo de R\$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) à vítima (fls. 639 e 459). Enfim, em dia incerto do ano de 2011, mas anterior ao dia 12 de julho, Edmar, acompanhado de comparsas ainda não identificados, após clonar o cartão bancários de José Bento da Costa, fingindo-se passar pelo proprietário do cartão, efetuou compras no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), prejuízo que foi assumido pelo banco Itaú, após José informar que não era o responsável pelos gastos (fls. 721 e 210). Ocorre que, conforme acima já mencionado, os documentos falsificados e os diversos cartões clonados, inclusive aqueles utilizados na prática dos crimes de estelionato já descritos, foram apreendidos em poder de Edmar, juntamente com cópia das faturas, possibilitando, assim, a identificação deste denunciado como autor dos estelionatos e da falsificação documental, bem como a de Fabrício como autor de um crime de falsificação e, ainda, a de todos os denunciados como integrantes da organização criminosa, sendo oportuno destacar que duas máquinas utilizadas para pagamentos com cartão magnético, subtraídas em data anterior, também foram apreendidas em poder de Edmar, anotando-se que há nos autos a informação de que Priscila e Fabrício foram os responsáveis pela subtração de um dos objetos (fls. 155/156), a demonstrar a estabilidade associativa criminosa."

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no qual, estando em termos, foram encadernados, dentre outros documentos, boletins de ocorrência (fls. 14/17, 45/46, 64/67, 72/73, 75/76, 86/87, 176/192, 401/402, 403/404, 405/406 e 493/494), auto de exibição e apreensão (fls. 18/21, 38/40 e 50/51), auto de entrega (fls. 63 e 171), relatórios investigativos (fls. 93/99 e 626/632), laudos dos cartões de crédito falsificados (fls. 634/637, 728/731 e 806/809), laudo veicular (fls. 641/644), laudo do notebook apreendido (fls. 814/816) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 967/969).

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia desfechada foi recebida,

determinando-se, na sequência, a citação dos acusados, na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal (fls. 973/974). Citados, os acusados Fabrício, Priscila e Rafael apresentaram resposta escrita por intermédio de defensores constituídos. Haja vista que o corréu Edmar não compareceu aos autos nem constituiu advogado, às fls. 1020/1022 o processo foi suspenso em relação a ele, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Outrossim, determinou-se a antecipação da produção de prova testemunhal, com base no artigo 82, também do Código de Processo Penal. Feito desmembrado à fl. 1024.

Já nestes autos, a defesa prévia do acusado Edmar foi acostada às fls. 1032/1035, por intermédio de defensor dativo. Por não ser o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução (fls. 1037/1038). Na aprazada, foram inquiridas as testemunhas Paulo Gustavo, Fátima Aparecida, Eduardo Onofre e Adalberto (fls. 1121/1122). Sobrevida a notícia da prisão do inculcado (fls. 1191/1197), foi designada nova audiência (fls. 1254/1255).

Na solenidade, iniciados os trabalhos, interrogou-se o réu (fls. 1305/1306). Na sequência, em vista da inexistência de diligências complementares, os debates orais foram convertidos em memoriais. Em sede de alegações finais, a acusação, em linhas gerais, propugnou pela integral procedência da denúncia (fls. 1330/1339). A defesa, por seu turno, protestou pela absolvição do acusado (fls. 1344/1348).

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Edmar Neves Dias, nas sanções dos crimes tipificados no artigo 288, caput, 297, caput, e 171, caput, por 04 vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

PRELIMINARMENTE:

Da inépcia da denúncia:

Alega a defesa do acusado, em suas alegações, ser a denúncia inepta, em decorrência da forma genérica com que os fatos nela foram narrados, não havendo, assim, descrição clara acerca do fato delituoso sub judice. Sem razão, contudo.

É que, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal:

"a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

E, na hipótese dos autos, é o que se verifica, na medida em que declinou ela as circunstâncias de tempo e local em que os fatos supostamente ocorreram. Mais seria desnecessário. Preliminar que vai afastada.

Do suposto cerceamento de defesa:

Embora a insatisfação expressada pela Defesa do acusado, ao argumento de que fora mitigado seu direito de contrapor as provas apresentadas pela acusação quando da audiência realizada - porquanto indeferido o pedido de redesignação da audiência -, dela não comungo.

Sucedendo que, sobrevindo a notícia da prisão de Edmar (fls. 1196/1197), o ato em questão foi designado no dia 30 de março de 2022 (fl. 1255) e o acusado devidamente intimado no dia 04 de maio de 2022 (fl. 1288). Contudo, foi somente no dia 05 de

junho de 2022, domingo, às 20:15min – um mês após a intimação do réu e um dia antes da realização da solenidade – os causídicos solicitaram habilitação aos autos. Não bastasse, anexaram uma procuração datada de 04 de março de 2022 (fls. 1300/1301).

Apesar de tudo, os trabalhos ocorreram de forma plena e satisfatória. Isto porque, logo pela manhã os nobres defensores tiveram acesso aos autos, sendo cientificados às 12:14min (fl. 1303). Outrossim, antes de iniciar a sessão de julgamento, o causídico conversou reservadamente com seu cliente, nos termos do artigo 185, §5º do Código de Processo Penal.

Rememora-se, ainda, que as audiências deste processo ocorreram em duas partes. Na primeira, aquela dos autos 0005590-53.2011.8.26.0266, foram inquiridas todas as testemunhas, em comum pelas partes, sendo que o acusado Edmar foi representado por um defensor dativo (vide fl. 1121). Muito embora o conjunto probatório tenha sido produzido em caráter antecipatório, à defesa do inculcado foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifestasse a respeito do conjunto probatório arrematado (vide fl. 1133). Esta, entretanto, ficou-se inerte (vide fl. 1137).

Assegurados, portanto, o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna, não há se falar em cerceamento de defesa.

#### NO MÉRITO:

A materialidade encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de exibição e apreensão (fls. 18/21, 38/40 e 50/51), pelas correspondências fabricadas (fls. 279/331, 442/492 e 495/522) e, principalmente, pelos laudos de fls. 634/637, 728/731 e 806/809. A autoria do acusado, doutra banda, mostrou-se cambaleante em relação ao crime de associação criminosa, sendo, portanto, o caso de absolvê-lo.

De antemão, sobre o ônus da prova, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão a conclusão alcançada nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional.

E, para tanto, soa adequado rememorar, com esboço na lição de Aury Lopes Júnior, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, “entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações” (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, pag. 45).

Ocorre que, no processo penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, “não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência” (ob. cit.) (Grifei).

Vale dizer, em âmbito penal, considerando a relevância e indisponibilidade da natureza da matéria discutida – liberdade do indivíduo – não existe uma distribuição na produção da prova, pois esta se encontra exclusivamente nas mãos do Ministério Público.

Ainda segundo o escólio do referido professor, “o que sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa.” (Grifo no original) (ob. cit.).

Em outras palavras, “carga é um conceito vinculado à noção de unilateralidade, logo, não passível de distribuição, mas sim de atribuição. No processo penal, a atribuição da carga probatória está nas mãos do acusador, não havendo carga para a defesa e tampouco possibilidade de o juiz auxiliar o MP a liberar-se dela (recusa ao ativismo judicial)” (ob. cit.).

Pode-se falar, portanto, que a defesa assume riscos pela perda de uma chance. “Assim, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa chance, assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance, logo, assunção do risco de uma sentença desfavorável. Exemplo típico é o exercício do direito de silêncio, calcado no nemo tenetur se detegere. Não gera um prejuízo processual, pois não existe uma carga. Contudo, potencializa o risco de uma sentença condenatória. Isso é inegável”(ob. cit.) (Grifei).

A conclusão a que se alcança, portanto, é a de que “não há uma carga para a defesa exatamente porque não se lhe atribui um prejuízo imediato e tampouco possui ela um dever de liberação. A questão desloca-se para a dimensão da assunção do risco pela perda de uma chance de obter a captura psíquica do juiz. O réu que cala assume o risco decorrente da perda da chance de obter o convencimento do juiz da veracidade” (ob. cit.) (Grifei).

Em suma, a necessidade de produção da prova para amparar a condenação do réu repousa unicamente nas mãos da acusação, não havendo que se falar em distribuição de cargas processuais.

Assentadas essas premissas, passo ao crime perquirido.

O interrogatório do acusado, em solo indiciário, restou prejudicado, porquanto foragido. Em Juízo (fl. 1307), asseverou estar na porta de um apartamento quando percebeu que um veículo o seguia. Posteriormente, já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, foi parado pelo automotor, de onde saíram os policiais e o prenderam. Explicou ainda que se encontrava no local para comprar um notebook de Fabrício, mas não sabe se aquela era a sua moradia. Disse que o conhece há um bom tempo, pois era seu amigo. Tocante a pessoa de Priscila, sabe que esta andava com Fabrício, mas nunca tiveram alguma aproximação. Sobre Rafael, o desconhece. À Acusação, confirmou que no fatídico dia estava em poder de um veículo Prisma, porém, não soube da apreensão de cartões de crédito nem retornou ao endereço onde se encontrava inicialmente. Desconhece a pessoa de Renato Brito Santana. À Defesa, respondeu que confessa estar no palco dos acontecimentos na data dos fatos, entretanto, que não sabe o motivo de tais imputações.

Quando confrontadas a versão externada pelo acusado com as demais provas produzidas, entendo não haver o Ministério Público se desincumbido de seu ônus no tocante à comprovação dos fatos alegados, ao menos estreme de qualquer dúvida.

A testemunha Judite, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 654), ao ser exibida uma fatura e um cartão de crédito em seu nome, afirmou desconhecer a correspondência. Explicou que nunca recebeu nem extraviou o referido cartão.

Estes, em linha gerais, foram os mesmos fatos articulados pelas testemunhas Eliene (fl. 656), José Humberto (fl. 657), João Alberto (fl. 658), Manoela das Chagas (fl. 663), Cícera (fl. 665), Emílio Carlos (fl. 667), Angelino (fl. 668), Regina (fl. 670), Maria Ramos (fl. 671), Antônio José (fl. 673), Alessandra Alves (fl. 674) e Aline Orsetti (fl. 718), em seus depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.

Já a testemunha Marco Antônio, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 645), disse que recebeu um cartão de crédito da Droga Raia, banco Itaú, sem tê-lo solicitado. Ligou no estabelecimento pedindo o cancelamento e disseram que

arrumariam o sistema. Contudo, posteriormente recebeu uma fatura cobrando a anuidade do cartão. Sequencialmente, contatou a empresa novamente solicitando o cancelamento.

No mesmo sentido os depoimento das testemunhas Renildo (fl. 547), Elisabeth (fl. 648) e Anthony (fl. 656), na etapa indiciária.

A testemunha Paulo Gustavo, por seu turno, em seu depoimento prestado tanto em solo indiciário (fl. 661 e 666) quanto em Juízo (fl. 1119), disse ter solicitado, em São Paulo, um cartão na loja Leroy Merlin, o qual seria usado única e exclusivamente para compra de materiais de construção. Sucede que ao recebê-lo, não o utilizou. Pontuou nunca ter extraviado o cartão. Entrementes, tempos depois, em sua residência, chegou uma cobrança no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) com movimentações no referido cartão que não havia efetuado. Assim, telefonou à loja, soube do procedimento a ser seguido e, por fim, não teve que arcar com o prejuízo. Em seguida, pediu o cancelamento do cartão.

A testemunha Angélica Aparecida, em solo indiciário (fl. 669), disse que teve conhecimento da fatura, bem como do cartão de crédito em seu nome, aludiu ter recebido, acerca de um mês, uma correspondência de cobrança no valor de R\$ 199,00. Em seguida, entrou em contato com a operadora e pediu o cancelamento tanto da compra quanto do cartão de crédito.

Já a testemunha Alexandre Riso, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 712), explicou que recebeu uma ligação de seu banco, haja vista que o cartão de crédito estava com "inconsistência na tarja magnética". Como solução, enviariam um novo cartão. Disse que antes da troca, foram realizadas duas movimentações indevidas, cobradas em faturas, porém, posteriormente, a empresa fez o estorno.

A testemunha José Bento, em seu depoimento em solo indiciário (fl. 773) e em Juízo (fl. 1373), asseverou que dos cartões falsificados exibidos somente possuía o cartão Super Mercado e Itaú. Explicou que no ano de 2011 teve ciência, através de uma fatura, de uma transação no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) – compra esta que não realizou. Na época, entrou em contato com as empresas e não teve que arcar com o valor. Por tais motivos, acabou cancelando todos os seus cartões, ficando apenas com um da Porto Seguro.

Por sua vez, a testemunha Tabajara Almeida, à fl. 797, enunciou ser proprietário do estabelecimento comercial Roasted Potato, localizado no Litoral Plaza Shopping, na cidade de Praia Grande. Afirmou ainda que teve subtraído do comércio uma máquina de cartão da marca CIELO, motivo pelo qual foi elaborado o Boletim de nº 2701/11, junto ao 1º DP de Praia Grande. Como o local possui algumas câmeras de segurança, compareceram alguns investigadores de polícia, aos quais foram cedidas as imagens.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Fátima Aparecida (fl. 1124) explicou ter solicitado um cartão junto ao Banco Bradesco, contudo, o cartão não chegou a sua residência, sendo posteriormente cobrada por faturas que sequer tinha conhecimento. Assim, entrou em contato com o banco e solucionou o problema.

O policial civil Eduardo Onofre, em Juízo (fl. 1126), relatou ter recebido notícia anônima quanto à existência de pessoas associadas na clonagem de cartões. Assim, realizou campanha em um condomínio residencial, uma vez que possuíam a informação de que aquele seria o local onde os criminosos confeccionavam os falsos objetos. No curso dessa diligência de observação, abordou um indivíduo de prenome Edmar, que estava em poder de diversos cartões, átimo em que este indicou os demais acusados.

Já o policial civil Adalberto, em Juízo (fl. 1123), afirmou que, ao que se recorda, houve uma notícia anônima relativa aos fatos, tendo sido feitas diligências de observação por 15 dias. Em uma determinada ocasião, Edmar foi abordado quando saía

de um apartamento, átimo em que descobriu que o suspeito estava em poder de diversos cartões bancários, dentro do automóvel. Ele admitiu que praticava clonagem de cartões e indicou outras pessoas que fariam parte do esquema criminoso. Foram então realizadas mais diligências, sendo uma delas no Shopping em Praia Grande, quando obtiveram a filmagem do furto de uma máquina de cartão de crédito e débito - resultando na identificação de Edmar e Priscila. Os demais corréus foram identificados por Edmar e compareceram à delegacia, quando intimados.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Estas são as provas. É de se ver, portanto, que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não se revelou robusto o suficiente a ensejar a condenação do acusado nas sanções previstas no artigo 288, caput, do Código Penal.

Haure-se dos autos que, após receberem denúncias anônimas acerca de uma quadrilha no qual se reuniu para efetuar clonagens de cartões e planejar os próximos crimes, que consistiam em dirigirem-se a estabelecimentos comerciais variados e, fingindo-se passar pelas pessoas cujo nome constava nos cartões falsificados, efetuarem compras - obtendo, assim, a vantagem econômica.

Na suspeita de se reunirem no apartamento nº 1134, situado a Estrada Gentil Perez, nº 1800, nesta comarca, policiais civis realizaram campana, durante 15 dias, nas proximidades do imóvel. Assim, constataram que Edmar, Rafael e Fabrício, diariamente, se encontravam na referida residência.

No dia 12 de julho de 2011, ao observarem Edmar saindo do condomínio do apartamento em um Chevrolet Prisma, os agentes estatais resolveram abordá-lo, ocasião em que ele trazia no interior do veículo 62 cartões magnéticos em branco, alguns cartões com o logotipo de bancos e lojas impressos (ainda sem a anotação de nomes) e, também, de muitos cartões clonados, em nome de terceiras pessoas (vide fls. 18/21).

No relatório de fls. 93/99, os policiais pontuaram que certos cartões ainda eram acompanhados da impressão das respectivas faturas, o que facilitava a aplicação das fraudes. Ocorre que, para dar ares de veracidade, elas possuíam todos os dados qualificativos dos verdadeiros correntistas/consumidores, o endereço da vítima e o limite de compras.

Os agentes narraram ainda que, durante a abordagem, Edmar teria confessado a utilização dos cartões para aplicação de golpes tanto no comércio local quanto em outras regiões, ter matéria prima necessária para fabricar e clonar os cartões, bem como contar com a ajuda de Fabrício, Rafael e Priscila. O primeiro e o segundo seriam responsáveis direto pela falsificação do cartão e, por algumas vezes, efetuavam compras com os objetos clonados. A terceira, em razão do sexo, da boa aparência e comunicação, colaborava com a equipe criminosa se passando pelas vítimas com documentação feminina.



Pois bem, pelo que consta dos autos, não resta positivado qualquer indício que o aponte como integrante de organização criminosa ou, ainda, de que tenham atuado conjuntamente para a prática de outros delitos, ao menos de forma habitual e cotidiana. Muito embora os agentes estatais tenham empreendido diligências por alguns dias, momento em que descobriram que o increpado comparecia ao apartamento de nº 1134, situado a Estrada Gentil Perez, nesta comarca, nenhuma outra prova foi produzida.

É claro que não se está a dizer que faltaram os policiais com a verdade frente a este Juízo. Todavia, a conclusão a que alcanço, é a de que a prova produzida pela acusação se vislumbra demasiadamente frágil.

Salienta-se também que, para a caracterização de entidade criminosa, não basta singela reunião de três ou mais pessoas com o objetivo de praticar um crime. A mera reunião de agentes não é suficiente para a configuração deste tipo penal. É necessário, pois, que haja um vínculo associativo permanente para a prática de condutas criminosas, um ajuste prévio dirigido à constituição de um laço recíproco, uma "societas sceleris", evidenciada pela contínua vinculação entre os criminosos.

É o entendimento jurisprudencial:

"Quadrilha ou bando - Caracterização - Reunião com caráter de estabilidade e permanência, em franca atividade - Prática delituosa reiterada - Sentença confirmada" (TJSP - JTJ 722/438).

Aliás, nesse sentido caminha a doutrina mais judiciosa:

"Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria." (Vicente Greco Filho).

Dessa forma, não restando evidenciado que o acusado mantinha um vínculo estável e duradouro com Fabrício, Rafael e Priscila, prova esta que incumbia à acusação que, ao contrário do que asseverou na denúncia e nas alegações finais, não comprovou adequadamente que estes atuaram com vínculo associativo permanente, de rigor a absolvição de Edmar das sanções previstas no artigo 288, caput, do Código Penal.

De resto, não é novidade que "se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 689).

O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição da parte acusada é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), observava:

"Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade".

Acerca dessa matéria:

"O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP). "Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata com como a matemática' Deram parcial provimento Unânime" (RJTJESGS 17/136).

Em resumo, a conclusão a que alcanço, é a de que a prova produzida pela acusação vislumbra-se demasiadamente frágil para edição de uma sentença condenatória, pois não embebida da certeza necessária.

Lado outro, as provas produzidas revelam, até com facilidade, a autoria do acusado Edmar nos crimes previstos nos artigos 171, caput, e 297, caput, ambos do Código Penal.

O delito previsto no artigo 171, caput, do CP, requer como requisitos fundamentais para sua configuração: (1) o emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (2) o induzimento ou manutenção da vítima em erro; (3) e, por fim, a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. No caso dos autos, estão presentes todos esses elementos.

Sobre o assunto, oportuno trazer à baila o escólio de Rogério Greco:

"(...) sendo a fraude o ponto central do delito de estelionato, podemos identificá-lo, outrossim, por meio dos seguintes elementos que integram a sua figura típica: a) conduta do agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; b) a vantagem ilícita pode ser para o próprio agente ou para terceiro; c) a vítima é induzida ou mantida em erro; d) o agente se vale de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução do seu fim. O crime de estelionato é regido pelo binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio. A conduta do agente, portanto, deve ser dirigida a obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio". (Código Penal Comentado. 6ª ed. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2012, pág. 540).

Na espécie, conforme antefalado, tem-se que as provas produzidas revelaram, até com facilidade, a autoria do acusado no delito em tela. Longe de qualquer dúvida também, dadas as provas coletadas, que o réu obteve vantagem ilícita, em razão do emprego de meio fraudulento.

Conforme se infere dos autos, policiais receberam denúncia apócrifa indicando o local dos fatos como sendo o lugar em que alguns indivíduos clonavam cartões de crédito e aplicavam golpes em terceiros. Já no fatídico dia, ao abordarem Edmar saindo do condomínio, em seu veículo foram encontrados inúmeros cartões de crédito (fls. 18/21). Neste sentido é o laudo de fls. 806/809, onde os experts constaram tratar-se de:

"62 cartões em branco;  
03 cartões Extra, com nome e número em branco;  
02 cartões Santander, com nome e número em branco;  
01 cartão Market Place Shopping Center, com nome e número em branco;  
01 cartão Litoral Plaza Shopping, com nome e número em branco;  
01 cartão Nossa Caixa, com nome e número em branco;  
01 cartão Banco do Brasil, com nome e número em branco;  
01 cartão Visa, com nome e número em branco;  
01 cartão Bradesco, com nome e número em branco;  
01 cartão Extra, em nome de Marcio Oliveira, sob o nº 5157400792439327;  
01 cartão Visa, em nome de Edmar N. Dias, sob o nº 4096027390072189;  
01 cartão Bradesco, em nome de Renato Brito Santana, sob o nº 496018850041012;

01 cartão Bradesco, em nome de Fabrício F. Da Silva, sob o nº 4096003230738834;  
01 cartão Bradesco, em nome de Fabrício F. Da Silva, sob o nº 4931000463380010;"

Apesar de em Juízo ter dado outros contornos aos fatos, na ocasião, em uma conversa com os policiais, o acusado confessou utilizar os cartões clonados para realizar compras no comércio local e outras regiões do Estado. Outrossim, que possuía maquinário para tanto (vide fls. 93/99).

O que também chamou a atenção dos agentes estatais foi o fato de alguns dos cartões estarem acompanhados da respectiva fatura (vide fls. 279/331, 442/492 e 495/522). Assim, intimaram as pessoas constantes em cada correspondência. Ulteriormente, ao visualizarem os documentos, 12 testemunhas reconheceram serem seus os dados impressos nas contas, outrossim, afirmaram que não tinham conta junto ao estabelecimento – a maioria relacionada a Farmácia Droga Raia (vide depoimentos de fls. 654, 656, 657, 658, 663, 665, 667, 668, 670, 671, 673, 674 e 718).

As testemunhas Angélica Aparecida (fl. 669), Alexandre Riso (fl. 712), José Bento (fls. 773 e 1119) e Paulo Gustavo (fl. 1125), pontuaram ainda que tiveram transações financeiras indevidas em seus cartões. Angélica disse que recebeu uma cobrança indevida no valor de R\$ 199,00, José Bento de R\$ 3.000,00 e Paulo Gustavo de R\$ 600,00. Em todos os casos, estes contataram a empresa bancária e esta arcou com os prejuízos.

Neste contexto, veja-se que o acusado, de forma fraudulenta, falsificava cartões de crédito em nome de terceiros e, se passando por eles, realizava compras em diversos estabelecimentos comerciais, auferindo, por conseguinte, vantagem indevida. Por fim, as vítimas entravam em contato com a operadora do cartão de crédito e esta arcava com as despesas, causando o réu, portanto, prejuízo alheio.

Não bastasse, conforme narrado, na apreensão dos diversos cartões de crédito falsificados, foi encontrada a cédula de identidade falsificada do inculcado. Conforme se verifica à fl. 105, Edmar tinha em seu poder uma identidade em nome de Ivan Ferreira Claudino, entretanto, com a sua fotografia.

Cumprе salientar que nos autos 0005590-53.2011.8.26.0266, o acusado Fabrício foi encontrado com um documento RG nº 008269837, em nome de Renato Brito Santana, com a sua fotografia. Quando as informações foram transmitidas ao Departamento de Identificação e de Registros da Polícia Civil de São Paulo, para confronto de digitais com a verdadeira cédula de identidade de Fabrício Ferreira da Silva, descobriu-se que, na verdade, ambas impressões digitais pertenciam ao acusado. Outrossim, que Renato Brito seria outra pessoa, cadastrado com número e digitais diversas (vide fls. 81/82 daqueles autos). Não bastasse, por fim, ao ser indagado, Fabrício asseverou que tal documento havia sido falsificado por Edmar, réu neste feito (vide fls. 1850/1851).

Ademais, não comporta acolhimento a tese defensiva de que não tinha o acusado consciência a respeito da ilicitude de sua conduta. A propósito, a teor do artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável.

Assim sendo, em vista do contexto probatório formado, forçosa a condenação do acusado Edmar Neves Dias nas sanções previstas nos artigos artigo 171, caput, e 297, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA:

Em relação ao crime de estelionato:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedente criminal. E isso porque, não havendo condenação definitiva (fora o caso de reincidência), tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer:

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado” (STTJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13.08.09).

Nesse sentido, aliás, é a súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado, não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 1268 - condenação pelo crime de receptação, processo nº 0025111-26.2006.8.26.0050, 23ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda). A este respeito, anoto que, se uma exasperação da reprimenda é de rigor, estando presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, em se tratando de um caso de reincidência específica, a resposta punitiva do Estado deve se fazer sentir com maior severidade, porquanto evidenciados o fracasso das penas anteriormente impostas, sobretudo em sua finalidade preventiva específica, e a recalcitrância do réu em amoldar sua conduta a padrões dignos de conduta. Assim, agravo a pena em 1/4, por se tratar de reincidência específica.

“PENAL. HEABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINDÊNCIA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. ACRÉSCIMO EM 1/4. RAZOABILIDADE. REINICIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DENEGACÃO DA ORDEM. 1. O Código Penal não especifica limites mínimo e máximo de exasperação ou redução de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, cabendo ao magistrado, de maneira prudente, com observância ao livre convencimento motivado, fixar o patamar que entender necessário e suficiente à espécie, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se, assim, de discricionariedade vinculada à devida fundamentação. 2. In casu, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/4, fração de aumento que não se mostra desarrazoada, tendo em vista escorreita valoração dada diante da reincidência específica do paciente. Não há falar, pois em constrangimento ilegal. (...)” (STJ-HC: 397898 RJ-2017/0097255-9. Relator: Ministra MARIATHEREZA DE ASSIS MOURA. DJ: 23/05/2017, T6. DP: DJe30/05/2017).

Ausentes quaisquer atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição, torno a pena, em definitivo, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Da continuidade delitiva:

Ante o conjunto probatório arregimentado, verifica-se haver o acusado praticado mais de um delito de estelionato, com idêntico modus operandi, condições de tempo,

lugar, maneira de execução semelhante, devendo, portanto, o crime subsequente ser considerado como continuação do primeiro.

Nesse sentido, quanto à continuidade delitiva, Guilherme de Souza Nucci preconiza: "a) são delitos da mesma espécie os que estiverem previstos no mesmo tipo penal. Nesse prisma, tanto faz sejam figuras simples ou qualificadas, dolosas ou culposas, tentadas ou consumadas" (Código Penal Anotado, 9ª Edição rev., atual e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. fl. 451).

Considerando que foram ao menos em número de quatro delitos de estelionato praticados, todos da mesma espécie, mediante mais de uma ação, com identidade de condições de tempo, lugar e maneira de execução, um dos delitos deve ser considerado como continuação do primeiro, aplicando-se, por conseguinte, a fração de 1/4 (art. 71, caput). Torno a pena, portanto, em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Em relação ao crime de falsificação de documento público:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O acusado não é possuidor de antecedente criminal. E isso porque, não havendo condenação definitiva (fora o caso de reincidência), tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer:

"(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STTJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13.08.09).

Nesse sentido, aliás, é a súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado, não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 1268 - condenação pelo crime de receptação, processo nº 0025111-26.2006.8.26.0050, 23ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda). A este respeito, anoto que, se uma exasperação da reprimenda é de rigor, estando presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, em se tratando de um caso de reincidência específica, a resposta punitiva do Estado deve se fazer sentir com maior severidade, porquanto evidenciados o fracasso das penas anteriormente impostas, sobretudo em sua finalidade preventiva específica, e a recalcitrância do réu em amoldar sua conduta a padrões dignos de conduta. Assim, agravo a pena em 1/4, por se tratar de reincidência específica.

"PENAL. HEABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINDÊNCIA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. ACRÉSCIMO EM 1/4. RAZOABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DENEGACÃO DA ORDEM. 1. O Código Penal não especifica limites mínimo e máximo de exasperação ou redução de

pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, cabendo ao magistrado, de maneira prudente, com observância ao livre convencimento motivado, fixar o patamar que entender necessário e suficiente à espécie, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se, assim, de discricionariedade vinculada à devida fundamentação.2. In casu, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/4, fração de aumento que não se mostra desarrazoada, tendo em vista escorreita valoração dada diante da reincidência específica do paciente. Não há falar, pois em constrangimento ilegal. (...)”(STJ-HC: 397898 RJ-2017/0097255-9. Relator: Ministra MARIATHEREZA DE ASSIS MOURA. DJ: 23/05/2017, T6. DP: DJe30/05/2017).

Ausentes quaisquer atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição, torno a pena, em definitivo, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Do concurso material de crimes:

Considerando que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de naturezas distintas estelionato e falsificação de documento público), com desígnios autônomos, deverão as penas cominadas a cada qual serem aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes).

Assim, deverá ser condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Ante a reincidência do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, §3º, do Código Penal).

Igualmente em vista da reincidência do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, nos termos do art. 44, inc. II, do CP, e de suspender condicionalmente sua execução, ex vi do art. 77, inc. I, do mesmo Diploma.

DIANTE DO EXPOSTO:

a) JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER o acusado EDMAR NEVES DIAS, já qualificado no preâmbulo destes autos, das imputações previstas no artigo 288, caput, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado EDMAR NEVES DIAS, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (QUATRO) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal. Isto por considerá-lo incurso nas sanções dos artigos 297, caput, e 171, caput, c.c. artigo 71, por quatro vezes, todos do Código Penal.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, ante a hipossuficiência ora reconhecida.

Não reconheço ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade. Consoante se infere das certidões constantes nos autos, o acusado voltou a delinquir pelo mesmo crime, o que demonstra seu descaso com a Justiça e o perigo a que expõe a sociedade

acaso colocado em liberdade. Vale dizer, a recalcitrância delitiva do acusado descortina a impossibilidade de sua manutenção em liberdade